



Cámara Federal de Casación Penal

Registro N° 422/24

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 7 días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro, se reúnen los miembros de la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la señora jueza doctora Angela E. Ledesma, como presidente, y los señores jueces doctores Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, como vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora Mariana Andrea Tellechea Suárez, a los efectos de resolver en la causa n° **FBB 1539/2021/2/CFC1** caratulada: "**Martínez, Jonathan Alejandro s/ recurso de casación**". Representa en la instancia al Ministerio Público Fiscal, el señor Fiscal General, doctor Javier A. De Luca y a la defensa particular de Jonathan Alejandro Martínez, los doctores Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: Angela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Guillermo J. Yacobucci.

La señora jueza **Angela E. Ledesma** dijo:

-I-

1°) La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca resolvió el 12 de septiembre de 2023: "Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 27/29, confirmándose la declaración de nulidad del dictamen fiscal de fs. 17/20".

2°) Contra dicha decisión el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación que fue concedido y mantenido.

3°) En la impugnación el representante del Ministerio Público Fiscal alegó que los magistrados podían no coincidir con la posición del Fiscal de grado, que se encuentra

suficientemente motivada, "pero bajo ninguna circunstancia pueden obligar al Fiscal a dictaminar en un sentido que contrarie su convicción personal".

Arguyó que lo que aquí se plantea es "el debate que se suscitó en el reconocido fallo 'QUIROGA'" y el rol de la acusación pública, en tanto en el sistema procesal vigente en la jurisdicción "la acción pública es ejercida exclusivamente por el Ministerio Público Fiscal (art. 5 del CPPN), garantizando así la imparcialidad de los magistrados que deben juzgar".

Aseveró que "si no hay acusación fiscal, la acción pública no puede proseguir su curso con un simple arbitrio de la judicatura" y que, en el caso, "al tratarse de cuestiones netamente objetivas, es decir, diferencias de criterios sobre el encuadramiento típico (o no) de un hecho ilícito, no existe contienda que tratar".

Añadió que con "la postura asumida por el Juzgado Federal de primera instancia, prácticamente se está retomando el procedimiento de control declarado inconstitucional por la CSJN (art. 348 *in fine* CPPN), con un condimento adicional que lo torna aún más grave: ni siquiera se aparta al fiscal interviniente, sino que se lo obliga a dictaminar en la dirección que procura el Poder Judicial".

Adicionó que ello no implica que los fiscales dispongan de la acción a su antojo, en tanto "los sistemas de control de disponibilidad de la acción (desestimación, archivo y sobreseimientos por igual) han evolucionado y se amoldaron al nuevo paradigma acusatorio que se encuentra en pleno apogeo, desde la puesta en vigencia del Código Procesal Penal Federal (ley 27.063)".

Finalmente, solicitó que se haga lugar al recurso y se revoque la resolución impugnada.

Hizo reserva del caso federal.

Fecha de firma: 07/05/2024

Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA



#37414165#410837926#20240507121338329



Cámara Federal de Casación Penal

4°) Posteriormente, los autos fueron puestos en término de oficina, oportunidad en la que se presentó el Fiscal General ante esta Cámara, Javier A. De Luca, quien adhirió a los argumentos del fiscal recurrente.

En primer término, coincidió en la semejanza del presente caso con el precedente "Quiroga" de la CSJN, en tanto se está cuestionando si el Poder Judicial puede obligar al Ministerio Público Fiscal, a que formule una acusación y requiera la elevación a juicio de la causa, cuando a criterio del titular de la acción los hechos no encuadran en ninguna figura legal.

Alegó que se afectó la independencia del Ministerio Público Fiscal por la intromisión en facultades que le son propias, en tanto "el dictamen fiscal estaba debidamente fundado en una posición hermenéutica que, se pueda o no coincidir, es plenamente válida. Por lo tanto, la nulidad decretada no tiene como origen un apartamiento normativo, sino una discrepancia con el juicio de subsunción que fue efectuado. De esa manera, al haber nulificado y dispuesto correr nueva vista al fiscal en los mismos términos, el magistrado se subrogó en las funciones acusatorias reservadas al Ministerio Público, pues la consecuencia jurídica derivada del auto interlocutorio era, al fin y al cabo, que el fiscal adapte su examen de tipicidad al del juzgado y solicitase la elevación a juicio".

Señaló que además la decisión es arbitraria en tanto el delito de tenencia o posesión de moneda falsa no existe en la legislación argentina, de modo que "agotada la investigación, el hallazgo de ese tipo de moneda en poder del imputado al momento del allanamiento o la requisita vehicular, por sí mismo y sin vinculación con alguna de las demás

conductas descriptas en la ley penal, no puede dar lugar a imputación alguna”.

En cuanto al delito de encubrimiento, criticó el argumento central del órgano jurisdiccional -que consideró que el fiscal postuló la incorporación *contra legem* de elementos al tipo penal del art. 277 CP-. Entendió que el alcance dado por los fiscales fue el correcto, en tanto los elementos objetivos de ese tipo son el delito precedente, la falta de intervención en ese delito previo, la inexistencia de promesa anterior, y todo ello con conocimiento y voluntad de realización de esas situaciones o bajo la posibilidad de que ello fuera así, y en el presente caso, no se acreditó, ni siquiera bajo un grado mínimo de sospecha, ninguno de los elementos objetivos y subjetivos apuntados.

En esa línea adicionó que no se demostró cómo “el mero secuestro de los seis billetes apócrifos en su poder, que se encontraron conjuntamente con otra gran cantidad de billetes de carácter no espurio, reúne los elementos cognitivos y volitivos necesarios del autor para con el hecho que se quería encubrir”.

En suma, consideró suficientemente fundado el dictamen del fiscal de grado y que por ello el postulado desincriminante era vinculante para el juez. Solicitó que se haga lugar al recuso y se revoque la resolución impugnada.

Finalmente, superada la etapa procesal prevista por el art. 468 del ordenamiento ritual, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

5º) Previo a todo, para una adecuada comprensión, corresponde realizar una reseña de los antecedentes del caso traído a estudio.

Conforme se desprende de las constancias de la causa, el proceso se inició en virtud de las actuaciones remitidas por la justicia de la provincia de Buenos Aires, originadas a raíz de una requisita vehicular practicada el 2/4/21 en la que se





Cámara Federal de Casación Penal

secuestró en poder de Jonathan Alejandro Martínez tres billetes de \$1000, que se presumían apócrifos. Forma parte de la plataforma fáctica también el hecho del 29 de junio de 2022, oportunidad en la que en el allanamiento llevado a cabo en el domicilio del nombrado, personal de Prefectura Naval Argentina secuestró, entre otras cosas, tres billetes de cien dólares estadounidenses (US\$ 100) que se presumían apócrifos.

El juez federal delegó la instrucción de conformidad con lo dispuesto por el art. 196 del CPPN en el Ministerio Público Fiscal. El acusador público solicitó la desestimación de los hechos y el archivo de las actuaciones, toda vez que, a su criterio, no constituían delito. El juez declaró la nulidad de los dictámenes y, con el argumento de que el caso se había iniciado por prevención de las fuerzas de seguridad, reasumió la investigación, con noticia fiscal.

El 3/10/22 el juez federal dispuso el procesamiento de Martínez por los dos hechos, encuadrándolos legalmente en las figuras de encubrimiento por receptación de cosa que sabía proveniente de un delito, doblemente agravados por ser los delitos precedentes especialmente graves y por haber actuado con ánimo de lucro, ambos concurriendo realmente entre sí (arts. 45, 55 y 277 inc. 1, ap. "c", e inc. 3, ap. "a" y "b", del CP).

Al contestar la vista prevista en el art. 346 del CPPN, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento de Martínez en los términos del inc. 3 del art. 336 del CPPN, por entender que los dos hechos eran atípicos ya que el delito de encubrimiento exigía la existencia de un delito previo en el cual no hubiere participado el acusado, extremos no acreditados. También sostuvo que los hechos sólo podrían encuadrarse como mera tenencia de moneda falsa, *per se* no punible, pues, al no existir puesta en

circulación o propia fabricación de la moneda, el bien jurídico no se había visto lesionado ni puesto objetivamente en peligro.

El 7/12/22 el juez declaró la nulidad del dictamen fiscal por considerar que no superaba el test de logicidad y legalidad porque, a su criterio, el juicio de tipicidad efectuado carecía de debida fundamentación, y corrió nueva vista para que requiera la elevación a juicio.

Esa decisión fue apelada, y el recurso fue sostenido por el fiscal general ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.

El 12/09/23 la Sala II del tribunal antes mencionado, por mayoría, rechazó el recurso y confirmó la nulidad del dictamen fiscal, por considerar que el pedido de sobreseimiento se motivó en una interpretación errónea del delito de encubrimiento previsto en el art. 277 del CP.

Ante ello el fiscal general interpuso el recurso de casación que ahora se trata.

6º) Ahora bien, corresponde resaltar que, conforme surge de la reseña que antecede, el representante del Ministerio Público Fiscal al contestar la vista del art. 346 del CPPN postuló el sobreseimiento del acusado Jonathan Alejandro Martínez (anteriormente había pedido la desestimación y archivo del caso).

También resulta importante destacar que esta postura fue respaldada por los demás representantes del Ministerio Público Fiscal que intervinieron en el caso (tanto el fiscal que mantuvo el recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca como el Fiscal General ante esta CFCP).

De este modo, toda vez que el acusador consideró atípicos los hechos investigados, la pretensión punitiva contra el nombrado feneció, en atención a que no existe interés en la persecución penal de esas conductas.

En consecuencia, los jueces que consideraron nulo el dictamen del acusador público -por no compartir su postura- soslayaron que el Ministerio Público Fiscal es el órgano

Fecha de firma: 07/05/2024

Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA



#37414165#410837926#20240507121338329



Cámara Federal de Casación Penal

encargado de promover la actuación de la justicia (art. 120 de la Constitución Nacional) y único titular de la acción penal (art. 5 del CPPN).

En estos términos, se observa que las decisiones -del juez federal y la mayoría de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca- tienen como finalidad exclusiva lograr la continuación de la persecución penal del encausado y la realización del juicio, sin tener en consideración la postura del Fiscal que desvinculaba al acusado del proceso penal mediante el dictamen cuestionado, en el que desarrolló adecuados argumentos para motivar su posición (más allá de que se comparta o no su criterio).

Admitir que el órgano jurisdiccional está facultado para avanzar en el proceso contra el acusado cuando el fiscal no ha sostenido la acusación, es violatorio de los derechos de defensa en juicio e *imparcialidad del juzgador*, así como el principio consustancial del proceso penal de contradicción.

En consecuencia, el órgano jurisdiccional no estaba autorizado para rechazar el pedido de sobreseimiento del imputado, y mediante las decisiones adoptadas se vio lesionada la garantía de imparcialidad del juzgador (arts. 75 inc. 22 de la CN, 8.1 de la CADH, 14.1 del PIDCP, 10 de la DUDH, 26 de la DADDH) y el principio acusatorio.

En lo que atañe a la independencia del Ministerio Público Fiscal, cabe recordar que los jueces no tienen la potestad de "obligar" a los fiscales a pronunciarse en favor de la prosecución de la persecución penal -como en el presente caso- cuando la Constitución proclama la independencia de dichos funcionarios, toda vez que -como ya lo ha dicho la CSJN en el caso "Quiroga" citado por el recurrente- resulta "insostenible que sea el tribunal encargado de controlar la investigación preparatoria el que pueda ordenarle al fiscal que

acuse. Pues el ejercicio de tal facultad de sustituir al acusador hace que los jueces, en vez de reaccionar frente a un estímulo externo en favor de la persecución, asuman un compromiso activo en favor de ella”.

Cabe recordar que también se ha sostenido en ese precedente que “la exigencia de ‘acusación’, si es que ha de salvaguardar la defensa en juicio y la imparcialidad como condiciones del debido proceso, presupone que dicho acto provenga de un tercero diferente de quien ha de juzgar acerca de su viabilidad, sin que tal principio pueda quedar limitado a la etapa del ‘debate’ (...), sino su vigencia debe extenderse a la etapa previa, de discusión acerca de la necesidad de su realización” (considerando 17).

En efecto, la función jurisdiccional que compete a cada tribunal interviniente se halla limitada por los términos del contradictorio, pues cualquier ejercicio de ella que trascienda el ámbito trazado por la propia controversia jurídica atenta contra la esencia misma de sistema de enjuiciamiento penal de corte acusatorio que diseña nuestra Constitución Nacional (art. 18, 75 inc. 22 de la CN, 26 de la DADDH, 10 y 11.1 de la DUDH, 8.1 de la CADH y 14.1 del PIDCyP – que expresamente ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los considerandos 7° y 15° del precedente “Casal” Fallos 328:3399-), cuyo paradigma esencial consiste en la separación de las funciones de enjuiciamiento y postulación.

El rol de perseguir y acusar debe ser independiente de juzgar y punir y, consecuentemente, debe estar a cargo de sujetos distintos (*Reglas de Mallorca, artículo 2°, inciso 1°*).

Ferrajoli explica que “la separación de juez y acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto estructural y lógico de todos los demás (...) Comporta no sólo la diferenciación entre los sujetos que desarrollan funciones de enjuiciamiento y los que tienen atribuidas las de

Fecha de firma: 07/05/2024

Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA



#37414165#410837926#20240507121338329



Cámara Federal de Casación Penal

postulación -con la consiguiente calidad de espectadores pasivos y desinteresados reservada a los primeros como consecuencia de la prohibición ne procedat iudex ex officio. La garantía de la separación, así entendida, representa, por una parte, una condición esencial de la imparcialidad (terzieta) del juez respecto a las partes de la causa, que, como se verá, es la primera de las garantías orgánicas que definen la figura del juez; por otra, un prepuesto de la carga de la imputación de la prueba, que pesan sobre la acusación, que son las primeras garantías procesales del juicio. (Ferrajoli, Luigi, "Derecho y Razón: Teoría del garantismo penal", Editorial Trotta, Madrid, 1989, p. 567).

Precisamente, este es el criterio que ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación tanto en el precedente "Llerena" (Fallos 328:1491).

En relación a este tópico me he expedido en las causas n° 4839 "Guzmán, José Marcelo s/ rec. de casación", registro 101/2004, rta. el 11 de marzo de 2004, n° 4722 "Torres, Emilio Héctor s/rec. de casación" registro 100/2004, rta. el 11 de marzo de 2004, n° 5617, "Pignato, Martín Mariano s/rec. de casación", reg. n° 478/05, de fecha 13 de abril de 2005, n° 5624, "Alegre, Julio Domingo s/rec. de casación", reg. n° 718/05, del 12 de septiembre de 2005, n° 5761, "Branca, Diego; Girini, Juan Carlos y Muñoz, Juan Manuel s/rec. de casación", reg n° 1078/05, rta. el 1° de diciembre de 2005, y n° 6068, "Balzola, Carlos Alberto s/rec. de casación", reg. n° 1089/05, de fecha 2 de diciembre de 2005, todas de la Sala III, entre muchísimas otras, a cuyos argumentos y citas me remito *mutatis mutandis* en honor a la brevedad.

Por los argumentos expuestos, propicio al acuerdo hacer lugar, sin costas, al recurso de deducido por el Ministerio Público Fiscal, anular la decisión impugnada y

sobrescribir a Jonathan Alejandro Martínez en orden a los hechos imputados, con la expresa mención de que la formación de esta causa no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado (artículos 336 inciso 3°, 456, 471, 474, 475, 530 y cc. del CPPN).

Tal es mi voto.

El señor juez **Alejandro W. Slokar** dijo:

Que, habrá de convenir con la magistrada preopinante que el recurso debe tener favorable acogida.

Ello así, por cuanto el Ministerio Público Fiscal tomó intervención uniforme en todas las instancias y dictaminó con base argumental postulando el sobreseimiento del encartado.

En estas circunstancias, los judicantes no se encuentran habilitados a sustituirlo en el rol acusador, dado que ello implica asumirse como parte interesada en la pesquisa, lo que pone en riesgo la garantía de imparcialidad. Ello no debe ser interpretado en términos de pugna de poder entre magistrados, sino de distribución de roles constitucionalmente establecida, en donde no puede mediar sustitución de funciones.

De tal suerte, cuando el dictamen fiscal alcanza a cubrir la exigencia de fundamentación, más allá de su acierto o no, asumir otra posición implicaría colisionar con los principios que rigen nuestro sistema de enjuiciamiento penal acusatorio, en particular el *ne procedat iudex ex officio* y el *nemo iudex sine actore*, con más la prohibición de la actuación jurisdiccional *ultra petita* (cfr. causa n° FSA 37154/2018/TO1/1/1/CFC1, caratulada: "Guarnieri, Mario Oscar Sebastián s/ recurso de casación, reg. n° 360/20, rta. 21/5/2020), comprometiendo así la imparcialidad y la defensa en juicio del justiciable.

En suma, se propicia al acuerdo hacer lugar, sin costas, al recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, anular la resolución recurrida y



Cámara Federal de Casación Penal

remitir las actuaciones a su origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento (arts. 471, 530 y ccds. CPPN).

Así lo vota.

El señor juez doctor **Guillermo J. Yacobucci** dijo:

Sellada la suerte del recurso con el voto concordante de mis colegas, solamente habré de agregar que el Ministerio Público Fiscal en su carácter de titular de la acción penal pública (art. 5 del CPPN), posee un ámbito de disponibilidad propio, sin embargo, entiendo que la opinión favorable del Fiscal, aún desde la perspectiva de las reglas propias del sistema acusatorio, no puede ser en modo alguno determinante, cuando de lo que se trata es de analizar la constitucionalidad y legalidad normativa.

Esto es así, pues la función esencial de la jurisdicción es preservar la vigencia de la Constitución, el Derecho y las leyes, ingresando esa perspectiva en un ámbito donde la opinión del acusador público no se impone *per se* frente a la competencia que nuestra propia carta constitucional ha otorgado a la magistratura judicial.

De tal forma, esta esfera de control de constitucionalidad no es disponible, sea cual fuere el sistema procesal que circunstancialmente se adopte. En cambio, cuando lo postulado por parte del Fiscal se encuentre vinculado con la disponibilidad de la acción, y que expresan una decisión político criminal, por principio, se encuentra bajo su ámbito funcional y por su naturaleza resulta vinculante para la jurisdicción.

En el caso, la postura sostenida por el representante del Ministerio Público Fiscal, se comparta o no, resulta materia disponible por la Fiscalía, pues su posición no infringe la Constitución Nacional ni causa un supuesto de

gravedad institucional o vulnera el orden público. Además, su postura está respaldada en las constancias de la causa.

Por otro lado, tanto el Fiscal General doctor Horacio Azzolín como el Fiscal General, doctor Javier Augusto De Luca, avalaron la decisión del agente fiscal de considerar la conducta de Jonathan Martínez como atípica, afirmando en ambos casos que el dictamen se encontraba debidamente fundado, y confirmando, por tanto, la posibilidad de emitir la posición liberatoria dictada en favor del causante.

Finalmente, cabe señalar que la postura seguida por el tribunal a quo, contraría de manera inequívoca y sin fundamento alguno, el criterio seguido por el Máximo Tribunal en el precedente "Quiroga", Fallos 327:5863, cuando indicó que *"sostener que dentro de nuestro sistema la función de perseguir penalmente es llevada adelante tanto por el fiscal como por los jueces no es suficiente para explicar que los jueces puedan tener la potestad de "obligar" a los fiscales a pronunciarse en favor de la prosecución de la persecución penal, cuando la Constitución proclama la independencia de dichos funcionarios. En este sentido, la afirmación de que la 'independencia del Ministerio Público' introducida por el art. 120 de la Constitución Nacional sólo significa la prohibición de instrucciones por parte del Poder Ejecutivo aparece como una mera afirmación dogmática, que desconoce el sentido de la separación entre jueces y fiscales como instrumento normativo básico para el aseguramiento del derecho de defensa"*.

De este modo, conforme las particulares circunstancias del *sub examine*, el tribunal a quo, carecía de jurisdicción para declarar la nulidad del dictamen fiscal, en el que se postuló el sobreseimiento de Martínez, que le fuera corrido en la oportunidad prevista en el art. 346 del CPPN.

De tal forma, la decisión impugnada carece de los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, lo que conlleva a su descalificación como acto judicial válido

Fecha de firma: 07/05/2024

Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA



#37414165#410837926#20240507121338329



Cámara Federal de Casación Penal

(Fallos: 274:462; 293:344; 308:914; 317:764; 320:2319, entre otros).

En consecuencia, comparto la solución que postula al acuerdo el doctor Alejandro W. Slokar.

Tal es mi voto.

Por ello, en mérito al resultado de la votación que antecede, el tribunal, **RESUELVE:**

HACER LUGAR, sin costas, al recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, **ANULAR** la resolución recurrida y, por mayoría, **REMITIR** las actuaciones a su origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento (arts. 471, 530 y cc. CPPN).

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/19 de la C.S.J.N.), remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fdo. Angela E. Ledesma, Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar.

Ante mi: Mariana Andrea Tellechea Suárez (Secretaria de Cámara).